08 筆記：反面容許構成要件錯誤、正當防衛、緊急避難

反面容許構成要件錯誤（偶然系列）

一、定義

- **客觀上**有阻卻違法前提事實存在，**主觀上**行為人不知道
- 與正面「誤想系列」相反：誤想 = 客觀無、主觀有；偶然 = 客觀有、主觀無

二、經典案例——偶然避難

- 甲恨仇人，拿石頭砸仇人窗戶 → 恰好仇人家瓦斯外洩 → 砸破窗戶反而讓空氣流通，救了全家
- 客觀上構成緊急避難的前提事實存在，但甲完全不知道

三、三種處理方式

學說	內容	結論
古典犯罪體系	違法性純客觀判斷 → 直接阻卻違法	阻卻違法（**已無人採**）
既遂說（多數說）	行為人犯意自始存在，無寬待理由	無法律效果，論原本之罪
未遂說	客觀好結果抵銷壞結果 → 結果不法被抵銷 → 僅剩行為不法	論**未遂犯**

四、理論基礎

- **行為不法** vs **結果不法**：
  - 既遂犯 = 行為不法 ＋ 結果不法
  - 未遂犯 = 僅有行為不法（無結果不法）
- **三階論**未遂說的關鍵字 =「**結果不法之抵銷**」
- **二階論**本就得出未遂結論（客觀✘ ＋ 主觀✔ = 未遂）

五、考試重點

- 反面（偶然系列）出題機率 **>** 正面（誤想系列），因為誤想系列已考多次
- 解題建議：列出**既遂說 ＋ 未遂說**兩說並陳
- 寫作位置：放在**違法性**階段（統一放違法性最簡單）

補充：誤想系列的過失判斷

- 誤想防衛改論過失犯時，「過失」≠ 對構成要件結果有無過失
- 「過失」= 行為人**對發生誤想這件事**有無過失
- 所有阻卻違法事由（正當防衛／緊急避難／業務正當行為／§21／被害人承諾）皆可能有誤想／偶然

正當防衛（§23）

一、基本架構

- **法條**：對於現在不法侵害，出於防衛自己或第三人權利之行為，不罰
- **核心思想**：合法者面對不法侵害，**不用低頭、不用躲避報警**，有權直接反擊
- **三要件**：
  1. 防衛情狀（前提事實）：現在不法侵害
  2. 防衛行為（手段適當）：適當性 ＋ 必要性
  3. 防衛意思（主觀要件）：認知到有現在不法侵害

二、前提事實——現在侵害

（一）判斷方法：反面剔除法

- 不是**將來**侵害、不是**過去**侵害 → 就是**現在**侵害
- 將來不能防衛：可報警／避難，不需自力救濟
- 過去不能防衛：那叫**報復**，於事無補

（二）現在 vs 將來的界線——四說

學說	標準	嚴格度
①著手標準說	侵害者行為須達未遂之著手	**最嚴格**
②有效防衛說	錯過此時點防衛將變困難或不切實際	**最寬鬆**
③**預備最後階段說**（實務採）	準備到下一步就動手的最後一步	中間
④具體危險說（徐志人老師）	侵害即將發生 ＋ 遲延防衛風險更大	近似②但重時空密切性

（三）案例比較

案例	①著手說	②有效說	③預備最後
平底鍋案（家暴爸拿球棒找小孩→兒子先用平底鍋打倒）	✘（還在找人）	✔	✔
家暴殺夫案（妻趁丈夫熟睡持刀殺之）	✘	✔（醒來無法防衛）	✘
KTV歹徒案（持槍歹徒找包廂→服務生先制伏）	✘（還在找包廂）	✔	✔

（四）預先設置防衛設備

- 設備何時設置不重要，重點是**起作用時** = 侵害開始時
- 無反對意見，通說均認不影響「現在侵害」之認定
- 手段過當是另一問題（家用電 OK ／高壓電 → 過當）

（五）現在 vs 過去的界線

- 區分點 = **行為的終了**（非「既遂」，非「完成」）
- **終了** = 法益侵害的結束
- 大部分狀態犯：既遂 = 終了（殺人、傷害）
- **繼續犯**：既遂 ≠ 終了（如私行拘禁§302，鎖進去既遂，放出來才終了）
- **竊盜罪**：
    - **既遂** = 持有關係改變的瞬間
    - **終了** = 對財產建立**穩固**的持有
    - 既遂到終了之間仍可正當防衛

三、前提事實——不法侵害

（一）形式不法

- 通說：只要具備**該當性 ＋ 違法性**即可，不要求罪責
- 對無罪責之人可正當防衛，但防衛權會被限制（社會倫理限制）

（二）民事不法

學說	立場	理由
多數說（肯定）	民事不法亦可正當防衛	**法秩序一體性**：民法上合法行為不應在刑法上變犯罪
少數說（否定）	僅限刑事不法	避免刑法侵犯其他法領域（刑事庭需判斷民事侵權）

- 常見民事不法案例：肉眼偷窺隱私（非§315之一）、使用竊盜（偷騎腳踏車）

（三）不法行為的主體

- 只有**人的行為**才有不法可言
- 純粹動物攻擊／自然力 → 無正當防衛空間
- 但動物攻擊背後有**人為故意或過失** → 可正當防衛
    - 故意：縱狗咬人
    - 過失：溜狗未繫狗鏈

（四）侵害是否存在的判斷視角

- 當下視角 vs 事後視角可能結論不同（如防搶演練案）
- 當下視角 → 正當防衛；事後視角 → 誤想防衛

（五）權利被侵害

1. **假侵害**（許澤天老師）：侵害自始不具威脅性（如不能未遂）→ 非正當防衛對象；若誤以為真 → 誤想防衛
    - 案例：拿水槍暴力討債 → 被害人太太誤以為真槍 → 誤想防衛

2. **純粹國家社會法益犯罪**：非正當防衛對象（維護社會秩序是警察任務）
3. **為第三人防衛**（緊急救助）：可以，但最低限度為第三人**未明確反對**

四、防衛行為——手段適當

（一）適當性 ＋ 必要性（無衡平性）

- **適當性**：防衛手段須**有效**（一般客觀上有可能消滅侵害即可；防衛失敗仍可成立正當防衛）
    - 無效手段：在私人土地上車的四輪全刺破 → 反而延展侵害 → 不算防衛
- **必要性**：所有有效手段中**損害最小者**
    - ≠ 純粹損害最小（逃跑報警不在考慮範圍）
    - 須參酌雙方年齡、性別、體力、有無武器等
- **無衡平性**：為保全微小利益而犧牲較大利益 → 仍可正當防衛

> ⚠ 正當防衛不等於比例原則。比例原則 = 適當 ＋ 必要 ＋ 衡平；正當防衛只要求**適當 ＋ 必要**。

（二）骨折不算重傷

- 重傷 = 毀敗或嚴重減損機能、重大不治難治之傷害
- 骨折可打石膏接回 → 非不可逆傷害 → **不算重傷**

五、社會倫理限制（權利濫用禁止原則）

> 德國通說承認；法無明文但學理上認為權利濫用禁止可上溯至憲法層次，故不違反罪刑法定原則。

四種類型及效果

類型	效果	說明
①**極端失衡**	**否定防衛權**	為保全趨近於零的利益而犧牲嚴重法益（如為喝剩的礦泉水將小偷絆倒致腦震盪）
②對無責任能力者的攻擊	**三階段防衛**	小孩／精神病患／智能障礙者的暴力攻擊
③家庭成員間的攻擊	**三階段防衛**	有反對意見：助長家暴＋家庭成員非自己選擇、無實質依據
④**意圖式挑唆防衛**	**否定防衛權**	假借防衛之名行攻擊之實

- **三階段防衛**：① 先逃跑 → ② 保護性防禦措施 → ③ 不得已才攻擊性防衛
- 僅具**攻擊性、暴力性**的行為才適用三階段防衛（非暴力侵害如偷手機、罵人無法逃跑）

挑唆防衛

類型	定義	效果
意圖式	故意激怒對方，設局等對方被激怒再反擊，假借防衛之名行攻擊之實	**否定防衛權**
非意圖式	無攻擊意圖但言語尖酸致對方動怒	**三階段防衛**

> 記憶口訣：最嚴重的兩種（極端失衡 ＋ 意圖式挑唆）→ 直接否定防衛權；其餘 → 三階段防衛。

六、防衛過當（§23但書）

- 效果放在**罪責**（非違法性）
- 過當 → 不能阻卻違法 → 最多減免罪責（減輕或免除）

（一）強度型過當

- 違反適當性或必要性
- 違反社會倫理限制中**非否定防衛權**的類型（該做123而未做）→ 仍可主張防衛過當減免

（二）延展型（擴張型）防衛過當

- 防衛的**時間不適當**
- 定義：行為人原先面臨不法侵害 → 排除侵害後 → 因驚恐在**時空不中斷**的情況下繼續攻擊

- 擴張解釋§23但書，使後段行為亦可適用防衛過當減免（對行為人更有利，多了免刑選項）
- 學界目前無明確反對意見（許恆達老師2012年引進、林書楷等支持）

適用限制：

1. 僅限**侵害開始後**的不適當防衛（侵害開始前不適用）
2. **局勢底定**、防衛者處於絕對優勢時 → 不再適用（如歹徒已昏迷喪失意識）

（三）免除罪責的防衛過當（許澤天老師引進）

- 源自**德國刑法§33**：出於慌亂、恐懼、驚嚇而超越防衛尺度 → 不罰
- 性質：無期待可能性 → 免除罪責（非阻卻違法）
- 客觀：強度型或延展型均可
- **主觀關鍵**：須為**軟弱情緒**（慌亂、恐懼、驚嚇），非強勢情緒（憤怒）
    - 軟弱情緒：悲傷、無助、想躲 → 值得同情 → 可免罪責
    - 強勢情緒：憤怒、想攻擊 → 僅一般防衛過當

七、主觀要件——防衛意思

- 只需**認知**到有現在不法侵害存在即可
- **不需要**保護權利的意欲（不要求防衛動機良善）
- 案例：在仇人車裝炸彈 → 發現小偷要偷車 → 為保護炸彈而與小偷扭打 → 仍算正當防衛

八、打架互毆與正當防衛

- 能證明誰先動手：先動手者不可正當防衛（合理）
- **不能證明誰先動手**：
    - 舊實務：雙方皆不準正當防衛 → 學者批評違反**罪疑惟輕**
    - 學說：應依罪疑惟輕，讓雙方皆可主張正當防衛

九、防衛行為與第三人

- 正當防衛只能對**不法侵害者**主張
- 為防衛而犧牲無辜第三人之物 → 對第三人只能主張**緊急避難**（非正當防衛）
- 例：搶路人LV雨傘反擊歹徒 → 雨傘毀損對路人論緊急避難

緊急避難（§24）

一、基本概念

- 與正當防衛不同：正當防衛針對不法侵害者；緊急避難被犧牲的對象**經常是無辜者**
- 法理基礎：**社會連帶**——社會成員應發揮互助精神，犧牲小利益救助他人

二、攻擊型 vs 防禦型

類型	被犧牲對象	出題頻率
攻擊型	無辜第三人	考試九成
防禦型	危難來源本身	較少考

- 防禦型案例：被臺灣黑熊攻擊 → 打死黑熊（黑熊即危難來源）

三、避難前提——急迫危難

（一）法益範圍

- 條文明列：**生命、身體、自由、財產**四種
- 爭議：例示性 or 列舉性？

學說	立場	理由
例示說	其他法益（名譽、隱私）亦可	不以文字為限
列舉說（老師支持）	僅此四種	**體系解釋**：§23寫「權利」（不限定），§24特別列舉四種 → 立法有意區分；緊急避難犧牲無辜，法益類型不宜放寬

（二）急迫危難的類型

1. **迫在眼前的危險**：如被動物追
2. **持續性的危險**：未爆彈型——何時爆、會不會爆不確定，但有高度可能性變成實害
    - 案例：地震後傾斜的房屋
    - **家暴殺夫案**的轉圜：通說認為不構成正當防衛的「現在侵害」→ 但可轉為緊急避難的「持續性危險」

> ⚠ 家暴殺夫案：雖構成急迫危難，但**避難手段（殺人）往往過不去**，因為可逃跑、報警（不符合「不得已」）。

（三）排除——合法行為

- 合法行為的相對人既不能正當防衛，也不能緊急避難（否則法秩序矛盾）

四、避難手段——不得已

- 條文要求「**不得已**」= **除此手段，別無他法**（比正當防衛嚴格）
- 正當防衛不考慮逃跑報警；緊急避難**必須考慮**
- 不符合不得已之案例：
    - 傷患送醫 → 可打119，不需強搶路人汽車
    - 被暴力討債 → 可報警逃跑，不得侵佔公款償債
    - 被惡犬攻擊 → 有其他人的雨傘可反擊時，不得犧牲更多

> 能用正當防衛就優先用，緊急避難要件更嚴苛。

五、限制

（一）公務或業務上特別義務（§24②）

- 適用對象：**警消、保全**等有特別義務之人
- 原則上不得主張緊急避難
- **例外**：法律不要求履行無效義務
    - 案例：手術中火災猛烈 → 醫護留下也救不了人（全身麻醉開腸剖肚）→ 可離開

（二）自招危難

類型	定義	可否緊急避難
故意自招	假借避難之名行攻擊之實的意圖（如故意激怒山豬再宰牠取肉）	**不可以**（嚴重權利濫用，無爭議）
過失自招	白目但無攻擊意圖（如無視告示牌拿竹竿逗豬致被攻擊）	學說多數：仍可 ／ **實務：不可以**

- 注意用語：正當防衛 → **挑唆防衛**；緊急避難 → **自招危難**（勿混用）

六、攻擊型避難的法益衡量

- **保全法益 > 犧牲法益** → 才可緊急避難（小於、等於皆不可）
- 法益順序：生命 > 身體 > 自由 > 財產

生命法益的特殊性

- **生命具最高位階**：任何法益對上生命都屬「算哪根蔥」
- **生命不準量化比較**：多數人的生命不優於少數人的生命
    - 不可為拯救多數而犧牲少數（電車難題→刑法採**康德義務論**立場）
    - 不可為拯救天才而犧牲智能障礙者

七、主觀要件

- 須具有**避難意思**（認知到危難存在）